



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

תיק מס': 315/12

בפני כב' המפקחת י. ענתבי-שרון

יעקב זערוור

התובע:

- נ ג ד -

1. אליס גרסון

הנתבעים:

2. יניב גרסון

ע"י ב"כ עו"ד אבירם מזרה

פ ס ק – ד י נ

עניינו של פסק דין זה בזכות לחניה קבועה ברכוש המשותף, סילוק יד ודמי שימוש ראויים.

א. עיקרי העובדות

1. עסקינן בבית משותף הידוע כגוש 30454 חלקה 30 והממוקם ברחוב הדישון 18 בשכונת מלחה בירושלים (להלן: "**הבית המשותף**").
2. התובע הוא בעליה של תת חלקה 4, במשותף בחלקים שווים עם הגב' אירית זערוור (להלן: "**דירת התובע**"). דירת התובע ממוקמת בקומה הראשונה של הבית המשותף ומוצמדת לה חניה בשטח 13.2 מ"ר, המסומנת בתשריט הבית המשותף בצבע כחול ובאות כ' (כן מוצמדות לדירת התובע מבואה, קרקע ומרפסת אשר אינן רלוונטיות להליך דנן).
3. הנתבעת 1 (להלן גם: "**אליס**") היא בעליה, בשלמות, של תת חלקה 3, המצויה בקומת הקרקע של הבית המשותף (להלן: "**דירת הנתבעים**"). לדירת הנתבעים אין הצמדה של חניה כלשהי (קיימת הצמדה של קרקע ומבואה, אשר אף הן אינן נוגעות למחלוקת שהיא נושא הליך זה).
4. הנתבע 2 (להלן גם: "**יניב**") הנו בנה של הנתבעת 1 ומחזיק מטעמה, ויחד איתה, בדירה.
5. בבית המשותף 12 יחידות משנה, כאשר ל-4 מהן בלבד רשומה חניה צמודה בפנקס הבתים המשותפים שבמרשם המקרקעין.
6. בקומת הקרקע של הבית המשותף, בשטח שבין הכביש של רחוב הדישון לבין הבית המשותף המבונה, קיימת רחבה, המהווה רכוש משותף. בחלק מרחבה זו רשומה זיקת הנאה וזכות קדימה לצורך מעבר חופשי להולכי רגל וכלי רכב, לטובת חלקות 22, 44 ו-24 בגוש 30454 (להלן: "**הרחבה**").
7. ביום 7.6.04 ניתן צו לרישום הבית המשותף וכן נרשם לו תקנון מוסכם. בתקנון המוסכם אין כל הוראות הנוגעות לחלוקה של "הרחבה" בין בעלי הדירות, וההגבלה היחידה הרשומה בתקנון המוסכם לגביה היא זיקת ההנאה וזכות הקדימה כאמור לעיל.
8. ביום 27.2.05 נרשם לבית המשותף תיקון לתקנון המוסכם ולפיו:



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

"ביחס ליחידות מספר 30/1 - 30/12 ייוסף סעיף:

1. בעלי היחידות יהיו רשאים להוציא חלקים מהרכוש המשותף בשטח זיקת ההנאה, לפי שטר 007706/0003 מתאריך 25.4.04 ולהצמידם לצורך חניה במקביל לכביש, ובלבד ויותר שטח מעבר לכלי רכב שלא יפחת מ-3.80 מטר.
2. שאר פרטי התקנון לא ישתנו ויישארו בעינם."
9. המחלוקת המתגלעת בתיק זה נוגעת לזכויות בשטח המסומן כ"רכוש משותף" בתשריט הבית המשותף וממוקם באותה רחבה (מסומן כ"חניה במחלוקת" בתשריט המודד ראובן אלסטר מיום 7.10.13 - להלן : **"שטח המחלוקת"**). שטח המחלוקת כולו ממוקם בחלקה של הרחבה בה רשומה "זיקת הנאה וזכות קדימה" כאמור לעיל.
10. התובע הגיש תביעה למתן סעד הצהרתי, צו מניעה קבוע וכן תביעה כספית בסך של 31,200 ₪. התובע מבקש הצהרה **"בדבר זכותו... בחנייה (שטח המחלוקת - י.ע.ש) שהוקצתה לדירתו..."**, וכן מתן צו מניעה קבוע **"אשר ימנע מהנתבעים מלחנות את רכבם בחניה זו"**.
11. הצדדים הגישו תצהירים מטעמים ודיוני הוכחות התקיימו בימים 29.5.13, 8.9.13, ביום 13.5.13 ערכתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים וב"כ הנתבעים.
12. משלא הובהר בשלב הראיות האם שטח המחלוקת מצוי בתחומי הרכוש המשותף של הבית המשותף או שמא חלקו מצוי בתחומי הבית הסמוך (רחוב הדישון 16), בשים לב לחשיבות וההשלכות האפשריות של ממצא בנושא זה, ובהיעדר כל חוות דעת מומחה מטעם הצדדים בנושא, הוריתי בהחלטתי מיום 10.9.13 על מינויו של המומחה המודד ראובן אלסטר (להלן : **"המומחה אלסטר"**), וזאת **"על מנת לבצע מדידה, ולקבוע, על רקע תשריט הבית המשותף, האם שטח המחלוקת (דהיינו מקום החניה אשר טוען התובע כי הוקצה לו בהסכמת כלל הדיירים ואילו הנתבע עושה בו שימוש בפועל), מצוי בתחומי הרכוש המשותף של רחוב הדישון 18 או שמא בתחומי הרכוש המשותף של הבניין הסמוך (רחוב דישון 16)"**.
13. ביום 13.10.13 התקבלה חוות דעת המודד, ומסקנות המומחה אלסטר העולות ממנה הן אלו :
"א. החניה (שטח המחלוקת - י.ע.ש) נמצאת בשטח בו קיימת זיקת הנאה להולכי רגל וכלי רכב וספק גדול בעיני אם מותרת בו חניה.
ב. מבחינת מיקומה הגיאוגרפי של החניה הרי כ 80% נמצאים ברחוב הדישון 18 וכן 20% ברחוב הדישון 16.
ג. "..."



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ב. טענות הצדדים

עיקרי טענות התובע

14. התובע טוען כי ברחבה מצויות 12 חניות המיועדות לשמש את כלל דיירי הבניין, וביניהן החניה המצויה בשטח המחלוקת. לטענתו, הוחלט על חלוקת החניות הכלולות במתחם בין בעלי הדירות, בהתאם לתנאים הנדרשים בחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק"). לטענת התובע, החניה המצויה בשטח המחלוקת הוקצתה, במסגרת חלוקה זו, לדירתו. דא עקא, שלטענתו, השתלטו הנתבעים על החניה בשטח המחלוקת והם אינם מאפשרים לו לעשות בה שימוש.

15. לטענת התובע, בישיבת האסיפה הכללית הוחלט לחלק את 12 החניות ולהצמיד חניה לכל דירה בבניין. באופן זה לכל ארבע הדירות להן כבר רשומה חניה צמודה תהיינה 2 חניות וליתר הדירות- חניה אחת. התובע טוען כי חלוקה זו נעשתה בהסכמת כל בעלי הדירות, ובהתאם להוראת סעיף 62 לחוק. לטענת התובע, כל בעלי הדירות, למעט הנתבעים, נוהגים לפי חלוקה מוסכמת זו וחונים רק בשטחי החניות שהוקצו להם.

16. התובע מדגיש, כי ההחלטה בדבר חלוקת החניות התקבלה גם בהסכמתה של אליס. אולם, באותה ישיבה החליטה אליס למכור את החניה שהוקצתה לה לבעלי תת חלקה 2, רוחמה ויעקב יעקובי (להלן: "יעקובי"), וזאת בסכום של 20,000 ₪. לטענת התובע, על אף שמשותפי הישיבה הבהירו לאליס באותו מעמד כי משמעות מעשיה היא כי לא תהיה בבעלותה חניה, היא ביצעה את המכר הלכה למעשה. מאז, טוען התובע, משתמשים יעקובי בחניה אשר הוקצתה לאליס ללא כל הפרעה או ערעור מצד הנתבעים.

17. התובע מדגיש כי מיום שהוחלט על החלוקה ואילך, מחנים הנתבעים את רכבם בשטח המחלוקת אשר הוקצה לו. התובע מבהיר כי ביום החלוקה בעליה של דירת התובע היה מר אליעזר גדות (ממנו רכש התובע באוקטובר 2010 את דירתו- להלן "גדות"). גדות השכיר את דירתו לשוכר שלא היה ברשותו כלי רכב, ועל כן לא צצו כל חיכוכים בעניין. עם זאת, מרגע שנכנס התובע לדירתו, לאחר רכישתה, דרש מהנתבעים מספר פעמים לפנות את שטח המחלוקת לשימוש- הן בעצמו והן באמצעות נציגות הבית המשותף. דא עקא, טוען התובע, ניסיונות אלו עלו בתוהו והנתבעים המשיכו לחנות את רכבם בשטח המחלוקת כעניין שבשגרה, על בסיס יומי.

18. התובע טוען בסיכומיו כי הנתבעים כלל לא חלקו על חלוקת החניות במתחם ועל חלוקת זכויות השימוש בהן.

19. עוד טוען התובע כי הראיות אשר הוצגו בהליך תומכות בכל טענותיו וכי הנתבע לא הביא ולו בדל ראיה הסותרת את הראיות שהציג.

20. ביחס לחוות דעתו של המומחה ראובן אלסטר (להלן: "חוות דעת המומד") טוען התובע בסיכומיו כי "אין מחלוקת עם בניין 16 ובניין זה לא תובע אף סנטימטר מהחניות של בניין 18, והשלים עם כך שהחנייה שייכת בשלמותה לבניין 18. מכל מקום במידה ויידרש, אין בעיה מבחינתי להעביר 20 אחוז משטח



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

החניה לבניין 16". ובהמשך מציין כי: "הנני מצהיר בזאת כי אסתפק ב-80% משטח החנייה שנגזלה ממני ושייכת לי במסגרת החלוקה שנעשתה בין הדיירים..."

21. התובע טוען כי טענתו של יניב לגבי "הסכם בעל פה" הקיים כביכול בינו לבין "בניין 16", לא גובתה בכל ראייה.

22. לטענת התובע, הנתבעים אינם יכולים להחזיק בחבל משתי קצותיו, היינו מחד גיסא לטעון כי החלוקה אינה חוקית, ומאידך גיסא למכור את החניה אשר הוקצתה להם מכוח אותה חלוקה למשפחת יעקובי.

23. התובע מוסיף וטוען כי הוא זכאי לפיצויים, וזאת בשים לב להיעדר תום לבם של הנתבעים אשר היו מודעים לכך ששטח המחלוקת מהווה חניה אשר הוקצתה לו, ויחד עם זאת בחרו למכור את החניה אשר הוקצתה להם ולעשות שימוש בשטח המחלוקת תוך סירוב עיקש לפנותו.

24. התובע טוען כי יש ליתן משקל מהותי לכך שאליס לא הגישה כל תצהיר מטעמה, וזאת על אף שהיא זו אשר הייתה נוכחת בזמן קבלת ההחלטה בדבר חלוקת הרחבה לחניות, ובשים לב לכך שיניב, אשר תצהיר הנתבעים הוגש על ידו, היה ביום החלוקה בן 13 בלבד.

25. התובע מוסיף וטוען כי עדותו של הנתבע 2 הייתה רצופת סתירות ואי אמיתות ולפיכך יש לדחות את גרסת הנתבעים.

עיקרי טענות הנתבעים

26. הנתבעים טוענים כי יש לדחות את התביעה מכל וכל.

27. בכתב ההגנה נטען, בין היתר, כך: "בשנת 2002 הוסכם בין כל בעלי הזכויות בבניין, על חלוקת השימוש ב-12 החניות שבבניין ואז, כל בעל זכויות בדירה, להלן: "הבעלים", סימן לעצמו את אחת החניות".

28. לטענת הנתבעים, היות ושטח המחלוקת איננו צמוד לאף אחת מיחידות המשנה של הבית המשותף והוא אף מצוי בתחום הכפוף לזיקת הנאה וזכות קדימה, לא הוכחו עילות התביעה.

29. הנתבעים טוענים, כי לא ניתן לעשות "הצמדה מיוחדת" בשטח רכוש משותף לגביו קיימת זיקת הנאה לטובת צדדים אחרים "ולגבי סוג שימוש אחר".

30. הנתבעים טוענים עוד כי יש לדחות את התביעה כנגד אליס שעה שלא הוכח כי היא עושה שימוש כלשהו בשטח המחלוקת.

31. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי האסיפה הכללית איננה מוסמכת להחליט בדבר הקצאת חניות מהרכוש המשותף לדירות מסוימות. כן נטען כי גם הנציגות אינה אוזרת בסמכות להקצות מקום חניה. קל וחומר כשמדובר בחניה "על בסיס מקום פנוי" המשיקה עם בניין אחר.

32. לטענת הנתבעים, התובע כלל לא היה נוכח ביום החלוקה ועל כן, לטענתם, אין לתובע "אפילו אבק מעמד של עד".



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

33. עוד טוענים הנתבעים כי טענת התובע לפיה לארבע הדירות להן קיימת הצמדה של חניה אחת במרשם המקרקעין, זכאות לחניה נוספת בעוד ליתר הדירות זכאות לחניה אחת בלבד, מתיישבת עם כך שליעקובי זכות לחניה נוספת על אף שכבר קיימת לו חניה אחת המוצמדת לדירתו במרשם המקרקעין.
34. לטענת הנתבעים, התובע לא הביא כל ראיה בדבר ההחלטה שהתקבלה לכאורה ב"יום החלוקה" ועל תוכנה המדויק. נטען, כי לא הוצג הסכם או תשריט חלוקה כלשהו. נטען עוד כי תמוה מדוע לא נרשם "הסכם החלוקה" ככל שהוא אכן קיים, בלשכת רישום המקרקעין.
35. נטען כי בתצהירים אשר הוגשו מטעם התובע אין זכר לכך שהתובע היה בישיבה בה הוחלט לכאורה על החלוקה, למועד הישיבה, למניין המשתתפים, ולפרוטוקול ככל שנערך. נטען כי העדויות מטעם התובע הן עדויות שמיעה כלליות וסתמיות אשר אינן קבילות.
36. הנתבעים טוענים כי ככל שהייתה חלוקה כנטען, הרי שהסכמות אלו בוטלו מאוחר יותר.
37. עוד נטען, כי ככל שנעשתה חלוקה כנטען על ידי התובע, הרי שהיא חסרת נפקות ממספר טעמים:
38. **ראשית**, טוענים הנתבעים, כי חלוקה זו מנוגדת להוראות סעיפים 62, 69, 71 ו-55 (ג) לחוק. נטען, כי מסעיף 55 (ג) לחוק יש ללמוד כי חלוקה של רכוש משותף ניתן לעשות בתקנון בלבד ולא באסיפה כללית, בכל אופן לא ניתן לעשות חלוקה שכזו כאשר עסקינן ב"מתקנים משותפים".
39. **שנית**, נטען כי מסעיף 69 לחוק יש ללמוד כי הנציגות מוסמכת לפעול רק בכל הנוגע ל"החזקה תקינה" של הרכוש המשותף ואילו חלוקת חניות איננה כזו.
40. **שלישית**, נטען כי "החלטת החלוקה" אף מנוגדת סעיף 71 לחוק שכן לא נרשמה בתקנון או בספר ההחלטות.
41. **רביעית**, נטען כי "החלטת החלוקה" לא התקבלה בהתאם לסעיף 62 לחוק שכן סעיף זה מורה כי לשם הצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית יש צורך בהסכמת כל בעלי הדירות, אולם כלל לא הוכח כי כל בעלי הדירות הסכימו לה.
42. הנתבעים טוענים בסיכומיהם כי אינם טוענים לזכאות בלעדית לחנות בשטח המחלוקת, אלא כי כאשר המקום פנוי, מחנה שם הנתבע 2 את רכבו מבלי להפריע לזכות מעבר.
43. עוד נטען, כי בשים לב לקביעות המומחה אלסטר בחות דעתו, ברי כי אם 20% משטח המחלוקת מצוי בבעלות הבית המשותף הסמוך (רח' הדישון 16), לא יכולים הנציגות או התובע לקבל כל החלטה בנוגע אליו.
44. בנוגע לתביעה הכספית בגין זכויות השימוש של התובע בשטח המחלוקת, עוגמת הנפש והפיצוי, טוענים הנתבעים כך:
45. בכל הנוגע לדרישה לקבלת דמי שימוש, נטען כי אין לתובע כל זכות בלעדית בשטח המחלוקת וממילא הוא אינו זכאי לקבל דמי שימוש בגין חנייה בו. הנתבעים מכחישים כי נגרמה לתובע עגמת נפש כלשהי



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

ומכל מקום, לטענתם, עליו להגיש תביעה כנגד הנציגות. באשר לטענה בדבר אובדן ימי עבודה טוענים הנתבעים כי זכות כזו אינה מוכרת בפסיקה או בחקיקה ולחלופין, אם היא מוכרת, אזי מגיע דווקא לנתבעים פיצוי בסך 20,000 ₪ נוכח, מה שהם מכנים "הטרדת התובע אותם".

46. הנתבעים מדגישים כי בהסכם המכר בין גדות לתובע לא נכללה חניה בשטח המחלוקת. לטענת הנתבעים, העובדה שהתובע לא צרף את הסכם מכר דירתו מלמדת כי לא הוקצתה לו כל זכות לחניה נוספת מעבר לזו הרשומה כצמודה לדירתו במרשם המקרקעין. נטען, כי גם אם הוקצתה החניה בשטח המחלוקת בעבר, הקצאה זו אינה ניתנת להעברה. בהקשר זה טוענים הנתבעים כי העובדה שהתובע נמנע מלצרף את הסכם המכר יוצרת חזקה כנגדו.

דיון והכרעה

47. רכוש משותף מוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: **החוק**) כך:

"רכוש משותף" - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת.

48. סעיף 55(ג) לחוק, דן בדרך הצמדת חלקים מהרכוש המשותף לדירה פלונית וקובע-

"בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן - התקנון), שחלק מסוים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד"

49. סעיף 62 (א) לחוק קובע:

"(א) בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות (ההדגשה שלי- י.ע.ש)".

50. הנה כי כן, על פי הוראות החוק, רק בהסכמת כל בעלי הדירות, ניתן להצמיד חלק מרכוש משותף לדירה פלונית, משמע ליתן זכות קניינית ברכוש המשותף לבעל דירה פלונית.

51. הוא הדין גם לגבי עשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף, אף אם אותו חלק לא הוצמד לדירה מסוימת במרשם המקרקעין (ראה: ע"א 2525/92, גבי וקרני ואוכרברג נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז (5) 850, רע"א 698/85, בן צור ואח' נ' נעים ששון ואח', תק- על (2) 732, י. וייסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף, (תשנ"ז-1997), עמ' 454-455).



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

52. על ההבחנה בין מתן "זכות קניינית", דהיינו ביצוע הצמדה, לבין "מתן רישיון לשימוש ייחודי" עומד המלומד א. אייזנשטיין, בספרו יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, עמ' 113-

"הצמדה" הנה הוצאת חלק מסוים מהרכוש המשותף ושיוכו (הצמדתו - בלשון החוק) לדירה פלונית. ההצמדה חייבת להיות קשורה לדירה ואין היא יכולה לעמוד בפני עצמה. משבוצעה ההצמדה, חדל החלק שהוצמד להיכלל ברכוש המשותף ודינו לכל דבר כדן הדירה שאליה הוצמד... (ההדגשות במקור)

ראוי להדגיש כי שימוש פיזי בשטח מסוים של הרכוש המשותף במשך תקופה ממושכת אינו מעניק לבעל הדירה המשתמש הצמדת שטח זה לדירתו. רק הצמדה הנעשית על פי הוראות החוק, מעניקה לו זכות קניינית בה".

(ראה גם - ע"א (מחוזי י-ם) 9502/06, רונית לומברוזו נ' קובנר מיכאל ואח', ניתן היום 7.8.07, פורסם ב"נבו").

53. פרופ' נ' זלצמן עמדה על הגדרתו של מוסד רשיון זה (במאמרה "רשיון במקרקעין", הפרקליט מב חוברת א (תשנ"ה), 24):

"רשיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל המקרקעין לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס. "רשות במקרקעין" באה להבחין מהענקת זכות במקרקעין שמאפייניה הם החזקה ושימוש בנכס, או שימוש בלבד.... הרשות נעדרת כוונת הקניה של זכות בנכס. אפשר שהיא תהא מעוגנת בחוזה שנקשר בין הצדדים וכך תצמיח למקבל הרשות זכות חוזית כלפי בעל המקרקעין... ואפשר שתנתן על ידי בעל המקרקעין ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית, אקט של רצון טוב, או תלמד משתיקתו ואי מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס. רשות גרידא באה להבחין איפוא מן הרשות החוזית. תוכנה של הרשות החוזית, משך קיומה ותנאי סיומה ילמדו מן ההסכם שבין הצדדים. רשות גרידא אינה מעניקה לבעליה זכות כלשהי כלפי בעל המקרקעין. היא בגדר היתר של רצון טוב שנותנו רשאי לבטלו בכל רגע...".

כתבה פרופ' זלצמן על ההשתק הקנייני:

"הפעלתו של ההשתק מותנית בהתקיימותן של נסיבות מיוחדות המעידות על הציפיה שיצר בעל המקרקעין אצל פלוני, בהסכמה מפורשת או בשתיקה, בדבר זכותו להחזיק או להשתמש בנכס ועל הסתמכותו של פלוני ושינוי מצבו לרעה כתוצאה מכך" (נ' זלצמן "רשיון במקרקעין", שם, 30)

54. ההסכמה הנדרשת יכולה להיות גם בעל פה ואין חובה כי תינתן בכתב דווקא (ראה: ע"א 815/81, יעקב כליפא ו-2 אח' נ' אלי שאול ואח', פ"ד לו(3), 78, עמ' 84-85, ע"א (חיפה) 1020/03, בובליל ישראל ואח' נ' שטיינר יוסף, תק-מח 2004(1), (להלן - "פרשת בובליל") 5244, ע"א 19/81 בנימין ביבי נ' ד"ר קרל הורברט ו-5 אח', פ"ד לו(2), 497, ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטרר, פד"י לא (1) 382).

55. אולם, ההסכמה תחייב את בעלי הדירות האחרים רק אם ידעו על קיומה. בפרשת בובליל נאמר בהקשר זה כך-

" לעמדת רישומו של הסכם הורתו ותכליתו ראייתית הן לגבי כלפי הבעלים והן כלפי צדדים שלישיים. המשמעות לכך היא שבמקרה בו גלוי וידוע היה כל העת לצדדים דבר קיומו של ההסכם ורישומיו ניכרו היטב עקב הבינוי



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

והנוהג בשטח מזה עשרות בשנים, לא קם צורך ראייתי נוסף ובפרט שהצדדים שניהם אינם מכחישים עצם קיום ההסכם וכל מחלוקתם מיוחסת לנפקותה המשפטית של מציאות נוהגת מוסכמת מקום לא נתבצע רישום בלשכת רישום המקרקעין..."

56. כשעסקינן בהסכמה על דרך של מתן רשות לשימוש במקרקעין (להבדיל ממתן זכות קניינית), הרי שניתן לחזור ממנה בכל עת. יפים לעניין זה הדברים שנאמרו בת.א (ת"א) 2816/03, **ציפורה קונצ'יצקי נ' דליה שפלן**, (להלן: "**פרשת קונצ'יצקי**") ניתן ביום 3.4.06, פורסם ב"נבו".

" הרי לכל היותר אפשר לראות את השימוש כנעשה בגדר הדוקטרינה של "רשיון במקרקעין" ללא תמורה. כפי שנפסק לא אחת, הרשאת חינוך שכזו ניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרשיון :

" רשות שנלמדת מכללל אינה מונעת את בעל המקרקעין מלהביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתו כלפי פלוני שאין הוא מוכן עוד להמשיכה. זו היא רשות חינוך המתחדשת מרגע לרגע, כל עוד לא פעל בעל המקרקעין לסילוקו של פלוני (פרופ' נ. זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב 24,57; וראה גם מ.דויטש קניין כרך ב' (התשנ"ט- 1999 414))."

57. עם זאת נקבע כי במקרים מיוחדים בהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מן ההסכמה ובהסתמך על מתן הרישיון השקיעו בעליו כספים רבים, תוענק הגנה לבעלי הרישיון (ראה: ע"א 7139/99 **אלוני נ' ארד ואח'**, פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 **קוגלמס נ' קוגלמס**, פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 **אריה בצר נ' צילביץ נחמה ואח'**, פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 **ציזיק נ' הורוביץ ואח'**, פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 **לוי נ' ויימן ואח'**, פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 **פלונית נ' פלונית** (פורסם באתר נבו)).

58. **בנסיבות בהן נעשתה חלוקה של זכויות השימוש בחלק מהרכוש המשותף בין כל בעלי הדירות**, ניתן ללמוד משתיקתם של בעלי הדירות- האחד כלפי משנהו- כהסכמה למתן רישיון לחלוקת זכויות השימוש ברכוש המשותף. רישיון זה יהיה בלתי הדיר כאשר בעלי הדירות כולם או חלקם הסתמכו על שתיקה זו ושינו מצבם לרעה בעקבותיה.

59. חלוקה מוסכמת מהסוג האמור משקפת את האפשרות הקיימת לבעלי הדירות לחלק ביניהם את זכות השימוש בחלקי הרכוש המשותף, וזאת להבדיל ממתן זכויות קנייניות, החייבות, כאמור, להיעשות על דרך של הצמדה וקבלת תוקף רישומי לכך, בהתאם להוראות סעיף 55(ג) לחוק. כאשר קיימת **חלוקה מוסכמת** של שימוש ברכוש המשותף בין בעלי דירות הבית המשותף, וחלוקה זו נוהגת שנים ארוכות, ניתנות תמורות שכן כל צד מקבל חלק מסוים ברכוש המשותף לשימוש ייחודי, תוך התחייבות מובנת מאליה להימנע משימוש בחלק אחר של הרכוש המשותף.

60. ודוק: בחלוקה מוסכמת מן הסוג האמור, בשונה ממתן רשות שימוש לבעל דירה מסוימת בלבד ברכוש המשותף, אין המדובר ב"ויתור" של בעל דירה על זכותו לעשות שימוש ברכוש המשותף לטובת בעל דירה אחרת בבית המשותף. שכן כאמור, עסקינן בחלוקה של זכויות השימוש ברכוש המשותף באופן שכל אחד מבעלי הדירות מוותר על זכותו לעשות שימוש בחלק מסוים מהרכוש המשותף, ומנגד- מרוויח את היכולת לעשות שימוש ייחודי בחלק אחר ממנו (ראה: ע"א (ת"א) 1295/03, **דוד נוי נ' זלמן קורנפלד**,



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

פורסם ב"נבו", ניתן ביום 10.7.06. לפיכך, החזרה מהסכמה בדבר חלוקת שימוש כזו לא תעשה בנקל ושינויה של אותה חלוקה מוסכמת עשוי לחייב הסכמה חדשה בין בעלי הדירות לחלוקה אחרת (ראה: ע"א (תל אביב-יפו) 1791/08, לוי נ' טובה, ניתן ביום 23.1.12 (פורסם ב"תקדין")).

61. המלומד פרופ' מיגל דויטש בספרו "קניין" (כרך א', עמוד 734-733), עוסק בשאלה "מה הדין... כאשר הנורמה אשר נוגדת את התקנון, או אשר אינה מוסדרת בו, התקבלה באמצעות הסכמה כוללת?" על כך הוא כותב את הדברים הבאים:

"במסגרת דיני השיתוף הכלליים מוכר המוסד של הסכם שיתוף; התקנון המוסכם משמש כמקבילה הטיפוסית להסכם שיתוף, בתחום הבתים המשותפים. ואכן, יש לשמור על הקבלה זו גם בשלב הטרם-רישומי. חופש ההתקשרות מחייב הכרה בתוקפו של הסכם בין כל בעלי הדירות, גם כאשר הוא לא זכה כלל, או עדיין לא זכה, למעמד תקנוני. על אף עליונותו הנורמטיבית של התקנון, ברי שאין לשלול את חופש ההתקשרות מחמת כך שההתקשרות לא באה לידי ביטוי (או עדיין לא באה לידי ביטוי, כאמור), בצורה של תקנון.

ואכן, לא אחת הפסיקה הכירה, ללא התחבטות, בתוקפם של הסכמים בין בעלי דירות, הן לעניין "חלוקה למעשה" של זכויות החזקה והשימוש ברכוש המשותף, והן לעניין זכויות בנייה. על הרשאות לשימוש ייחודי של בעל דירה ברכוש המשותף או בחלקו יחולו הכללים הרגילים החלים על הרשאות שימוש, ובראשם הכללים הנוגעים לאופן סיום הרשות, ולשאלת הפיצוי של בר הרשות בעקבות סיום הרשות. הסכמים בעניין זה, כך נפסק, אינן טעונים מסמך בכתב.

מהו מעמדה המדויק של הסכמה חוץ תקנונית של כל בעלי הדירות כאמור? אין ספק, כי היא יכולה לנגוד גם תקנון מוסכם וגם תקנון מצוי. על כן, היעדר הרישום של אותו הסכם כתקנון, אינו גורע ממעמדו בין הצדדים המקוריים להסכם. האם הקביעה בסעיף 64 לתקנון, בדבר כך שרואים את התקנון המצוי כתקנון שנרשם, במקרה של תקנון מוסכם בלתי רשום, אינה גוררת בכל זאת את שלילת התוקף של הסכם לבר תקנוני, הנוגד את התקנון הרשום, ביחסי הצדדים לו? התשובה לכך היא בשלילה. אף לגבי עניינים אשר מוסדרים בתקנון מוסכם שנרשם, יכולים הצדדים להגיע להסדר מחייב מחוץ לתקנון, אשר נוגד אותו. מובן, כי יהיה צורך לפרש תחילה את ההסכמה, ולאתר כוונה לגבור על הוראות התקנון, אולם אין טעם כלשהו שבתקנת הציבור לשלילת הפעלתו של חופש ההתקשרות בעניין זה".

62. בהקשר זה אזכיר את סעיף 12 (ב) לתקנון המצוי, הקובע כי: "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה". שעה שנמצא כי כל בעלי הדירות הסכימו לחלוקת הרכוש המשותף או חלקו, הרי שהחלטתם בוודאי איננה מנוגדת לתקנון, אלא לכל היותר מסדירה נושא אשר אינו מופיע בו בפירוט, ובאופן התואם את התקנון עצמו. אמנם, ההחלטה לא נרשמה בספר ההחלטות (ראה סעיף 71 (א) לחוק), אולם, כאמור, היא תחייב בעל דירה שבא בנעלי בעל הדירה שהיה שותף להסכמה, כל עוד אותו רוכש ידע על ההסכמה שהושגה.

63. על רקע דברים אלו, נפנה לבחינת נסיבות המקרה שהוא נושא דיוננו. ראשון-ראשון ואחרון-אחרון.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

מן הכלל אל הפרט

שתי הערות מקדימות:

64. כאמור, על פי חוות דעתו של המומחה אלסטר, שהצדדים לא חלקו עליה בסיכומיהם, 80% משטח המחלוקת מצוי בתחומי הבית המשותף, ואילו 20% ממנו שייכים לבית משותף אחר, סמוך (רחוב הדישון 16). לפיכך, כל קביעותי להלן בכל הנוגע ל"שטח המחלוקת" יתייחסו אך ורק לאותם 80% המהווים חלק מן הרכוש המשותף של הבית המשותף שהוא נושא הליך זה. אין בסמכותי לדון בחזקה של בעל דירה ברכוש משותף של בית משותף בו הוא אינו בעל דירה, וממילא בעלי הדירות של אותו בית סמוך (רחוב הדישון 16), אינם צד בהליך שבפני ועמדתם לא נשמעה. מסיכומי התובע עולה כי דברים אלו ידועים ומובנים לו שכן הצהיר שם כי יסתפק באותם 80% משטח המחלוקת.

65. אוסיף גם את המובן מאליו, היינו כי כל הכרעותי בפסק הדין מוגבלות אך ורק לתחום היחסים שבין הצדדים להליך זה.

מה טיבה של החניה בשטח המחלוקת שעה שהוא מצוי בתחומי זיקת הנאה -

66. ראשית, אדרש לשאלה מקדמית שמהותה האם קיימת אפשרות משפטית לעשות שימוש קבוע בתחומי הרכוש המשותף לצורכי חניה, שעה שעל מקום אותה חניה ברכוש המשותף חלה זיקת הנאה בדמות "זכות גישה למעבר חופשי ולהולכי רגל".

67. על פי תשריט הבית המשותף, וכפי שאף צוין בחוות דעת המודד, חלקה של הרחבה, בה מצוי שטח המחלוקת, כפוף לזיקת הנאה לטובת חלקות 22,24,44 "לצורך מעבר חופשי להולכי רכב וכלי רכב".

68. עיון בתיק הבית המשותף מעלה כי ביום 30.1.05, הגיש מינהל מקרקעי ישראל (בשם רשות הפיתוח אשר הייתה רשומה כבעלת המקרקעין הידועים כגוש 30454 חלקות 22,24,30,44) בקשה לתיקון תקנון מוסכם. בהתאם לבקשה זו, תוקן ביום 27.2.05 התקנון המוסכם כך שהתווספה לו הוראה לפיה:

" ביחס ליחידות משנה מספר 30/1-30/12 ייוסף סעיף:

בעלי היחידות יהיו רשאים להוציא חלקים מהרכוש המשותף בשטח זיקת הנאה, לפי שטר 007706/0003 מתאריך 25.4.04 ולהצמידם לצורך חניה במקביל לכביש, ובלבד שיוותר שטח מעבר לכלי רכב שלא יפחת מ-3.80 מטר".

69. הנה כי כן, היות ובעלי החלקות הנהנות מזיקת הנאה, כמו גם בעלי החלקה הכפופה לה (אשר למעשה בזמן הרלוונטי דובר באותם בעלים- רשות הפיתוח) הסכימו להצמדה עקרונית של חניות בשטח הרחבה ובמשתמע לצמצום זכות זיקת הנאה של החלקות הנהנות, לא קיים כל קושי לבצע באופן תיאורטי הצמדה של חניות על תחומי הרחבה הכפופה לזיקת הנאה. הדבר נכון כמובן, כל עוד היקף החניה תואם את הקבוע בתקנון המוסכם ומותיר שטח מעבר לכלי רכב שלא יפחת מ-3.80 מטר. במצב דברים זה אין צורך להכריע בשאלה האם ככלל, אסורה חניה קבועה בשטח אשר חלה עליו זיקת הנאה מהסוג הנדון.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

האם הייתה הסכמה של כל בעלי הדירות בדבר חלוקת הרחבה לחניות, ולמתן זכות שימוש ייחודי לכל דירה בחניה פרטנית בתחומי הרחבה?

70. אקדים את המאוחר ואבהיר כבר עתה כי מן הראיות שהונחו על שולחני והעדויות שנשמעו בפני, שוכנעתי כי אכן הייתה חלוקה של הרחבה ל- 12 חניות, באופן בו ניתנה זכות לשימוש ייחודי לכל בעל דירה בשטח מסוים ברחבה לצורך שימוש בו כחניה, לרבות לבעלי הדירות שכבר הוצמדה להם חניה אחת במרשם המקרקעין. כן שוכנעתי כי לחלוקה זו הסכימו כל בעלי הדירות, ואף נהגו ונוהגים לפיה- הלכה למעשה.

71. להלן אנמק את מסקנותיי אלה.

72. בראש ובראשונה תמוהה בעיני הכחשתם של הנתבעים את החלוקה הנטענת, ואת טענותיהם הרבות בדבר היעדר כל תוקף משפטי ומחייב לחלוקה זו, **שעה שהם עצמם נהגו על פיה ואף זכו לטובת הנאה בהסתמך עליה.**

73. יניב הודה בכתב הגנתו ואף בחקירתו הנגדית, כי הנתבעים מכרו ליעקובי את החניה אשר הוקצתה לדירתם במסגרת אותה הסכמת בעלי דירות, תמורת סך של 5,000 דולר. בלשונו:

”ש. אתה יודע שאספו כסף מהשכנים והביאו גם מודד, הצהירו במפורש שנעשתה חלוקה וקיבלת חניה, למה אתה מכחיש את זה.

ת. אני לא מכחיש את זה שקיבלתי חניה, אני מודה שהייתה לי חניה, ושנתתי זכות למר יעקובי להחנות את רכבו שם.

ש. תמורת מה העברת את הזכות הזו כמחווה או כי קיבלת 5,000 דולר.

ת. תמורת הסכום שרשום בתצהיר שלי, מפנה לתצהירי.

ש. אתה מאשר שקיבלת 5,000 דולר ממר יעקובי.

ת. הסכום שקיבלתי הוא 5,000 דולר.”

74. מכאן ברי כי נעשתה חלוקה בפועל של חניות מתוך הרכוש המשותף לבעלי הדירות, אם תרצה- ניתנה בפועל זכות שימוש ייחודית בחניה מסוימת לבעלי הדירות, ולראייה כי אף הנתבעים קיבלו חניה כזו ומכרו, לכל הפחות, את זכויות השימוש בה.

75. הנתבע 2 עצמו, בפתח תצהיר עדותו הראשית (בסעיף 2א) הצהיר כך-

” ב- 2002 הוסכם בין כל בעלי הזכויות בבניין, על חלוקת השימוש ב-12 החניות שבבניין ואז, כל בעל זכויות בדירה, להלן: ”הבעלים”, סימן לעצמו את אחת החניות. ומאז- עשה בה שימוש ייחודי ובלעדי...”

76. שעה שהנתבעים עצמם הסתמכו על חלוקת החניות ואף כאמור, מכרו את זכויותיהם בתמורה, הם מושתקים ומנועים מלטעון כי חלוקת החניות בטלה וחסרת תוקף שכן כביכול נעשתה בהיעדר סמכות ובהיעדר הסכמת כל בעלי הדירות כדן.

77. על אף שהן מעדויות התביעה והן מעדויות ההגנה עלה כי התקיימה אסיפה כללית בה הוחלט על הקצאת חניות וכי חניות אלו סומנו בתשריט, לא הוצג בפני פרוטוקול האסיפה הכללית או התשריט שנילווה לו.



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

בנושא זה התגלעו הבדלי גרסאות, כאשר התובע טען כי מסמכים אלו מצויים בידי יעקובי, אשר שימש בעבר כיו"ר הנציגות והוא נמנע מלהציגם, ואילו יעקובי טען כי העביר מסמכים אלו לנציגות שהחליפה אותו. הנציגות "החדשה" עמדה על כך שמסמכים אלו נותרו בידי יעקובי והוא נמנע מלהעבירם על אף שהתבקש לעשות כן. **כך או כך, לא הייתה מחלוקת על כך שמסמכים אלו קיימים. המחלוקת למעשה, נוגעת לשאלה כמה חניות הוקצו במסגרת אותה אסיפה, האם לתובע הוקצתה החניה בשטח המחלוקת- כטענתו, והאם מבחינה משפטית ניתן בכלל לבצע חלוקה של חניות כפי שנעשתה ומה תוקפה.**

78. כאמור לעיל, מצאתי כי הנתבעים מנועים ומושתקים מלטעון כנגד תוקפה המשפטי של חלוקת החניות שעה שהם עצמם פעלו בהתאם לחלוקה זו, הסתמכו עליה ואף מכרו את הזכות שקיבלו בחניה, מסגרת אותה חלוקה.

79. למעלה מן הצורך אציין עוד כי אף מבחינה משפטית לא מצאתי קושי בביצוע חלוקה של חניות לשימוש בלעדי של כל אחד מבעלי הדירות, אף אם לחלוקה זו לא ניתן ביטוי במרשם המקרקעין, ובלבד שחלוקה זו מבוצעת בהסכמת **כל** בעלי הדירות- כמצוות סעיף 62 (א) לחוק וכי אין מניעה אחרת בדיון. שוכנעתי, אם כן, וכפי שיפורט להלן, כי חלוקה זו של החניות אכן בוצעה בהסכמת כל בעלי הדירות. לפיכך, טענת הנתבעים כי הנציגות אינה מוסמכת לבצע חלוקה כאמור כלל אינה רלוונטית שכן לא מדובר על חלוקה של הנציגות כי אם חלוקה של בעלי הדירות עצמם. שנית, גם המכשול הקיים לכאורה נוכח קיומה של זיקת ההנאה הוסר, שעה שנמצא, כאמור, כי התקנון המוסכם מאפשר את הצמדת החניות וכי הפגיעה בזכות זיקת ההנאה של החלקות "הנהנות", נעשתה בהסכמתן של אלו. עוד יש להוסיף, כי אין מדובר במקרה הנדון מסוג "מתקנים" אשר נאסר על הצמדתם בסעיף 55 (ג) לחוק.

80. **נותר, אם כן, לבחון מה הייתה טיבה של החלוקה, ובין היתר, האם חולקו בפועל 12 חניות- חניה לכל דירה- כטענת התובע, או שמא חולק מספר חניות מועט יותר- כטענת הנתבע. כן יש לבחון האם במסגרת חלוקת החניה הוקצתה חניה גם לתובע, ואם כן - האם מדובר בחניה המצויה בשטח המחלוקת. לפיכך, אעמוד להלן על הראיות הקיימות בנדון.**

81. לטענת התובע בכתב תביעתו, כאמור, בישיבת האסיפה הכללית מיום 2.4.08 הוסדר השימוש ב-12 חניות בתחומי הרחבה והוחלט להצמיד לכל אחת ואחת מדירות הבית המשותף. התובע לא הציג פרוטוקול זה, שכן לטענתו, מסמך זה היה מצוי בידי מי ששימש כיו"ר הנציגות הקודם- מר יעקובי. יעקובי, כאמור, זומן למתן עדות והתבקש להביא עמו את מלוא החומר הרלוונטי (לרבות פרוטוקול האסיפה הכללית בו הוחלט על חלוקת החניות והתשריט בו ניתן לראות את החלוקה בפועל), אולם **בעדותו בפני טען כי אין בידי את המסמכים שכן העבירם, כביכול, לנציגות שמונתה אחריו - למיטב זכרונו, למר חיים כהן** (ראה פרוטוקול מיום 29.5.13, עמ' 9 שורות 8-9). עם זאת, יעקובי הודה בעדותו כי התבצעה חלוקה של חניות בין בעלי הדירות, אולם טען כי היא לא הבשילה **"לשלב מוגמר"** וכי- **בשלב האחרון של השרטוטים הם נגעו ל-11 חניות"** (עמ' 8 לפרוטוקול מיום 29.5.13 שורות 6-7).



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

82. מר חיים כהן (להלן: "כהן"), טען בעדותו כי לא קיבל העתק וכי התשריט נשאר אצל מר יעקובי ששימש כיו"ר הנציגות (ראה עמ' 5 לפרוטוקול מיום 29.5.13, שורות 4-5). כשנשאל כהן מפורשות "למה אתה לא מבקש העתק מהשרטוט מיעקובי" השיב: **"ביקשנו מיעקובי ולא קיבלנו"** (ראה בעמ' 6 שורות 6-7).

83. התובע טען בעדותו כי נעשו ניסיונות רבים להשיג את החומר הרלוונטי (בכלל זה את פרוטוקול האסיפה הכללית בה הוחלט על חלוקת החניות ואת התשריט שבו הן מסומנות) - אך ללא הועיל:

"ש. יש לך את הפרוטוקול של 2004 שעל פיו כביכול נעשתה החלוקה האם ראית פרוטוקול כזה.

ת. לא ראיתי.

ש. למה לא דרשת את הפרוטוקול הזה ממר יעקובי?

ת. דרשתי את הפרוטוקול מהוועד וכן לא אחת ממר יעקובי והוא טען בפניי שאין לו שום ניירות בחזקתו והוא העביר את הניירות לוועד שאחריו בראשו צבי רביב וחיים כהן. פניתי לרביב ולכהן וביקשתי את המסמכים והם אמרו מפורשות שמר יעקובי לא העביר אליהם שום מסמך שקשור לחניות. חזרתי ושב ליעקובי ונאמר לי ממנו שאין לו שום מסמך לתת לי. מכיוון שהוא עצמו מעורב עד צוואר בעניין החנייה".

ש. למה לא ביקשת את הפרוטוקול ממר גדות.

ת. גדות לא היה נוכח בישיבה הזו. פניתי לכל הדיירים כולם וטענו שאין להם והניירת אצל יעקובי..."

84. כהן הבהיר בעדותו כי היה נוכח בישיבה בה הוחלט לחלק את החניות ואף העיד כי **"בתרשים סומן מקום החניה של כל דייר. וכל דייר חתם שהוא מסכים על מקום החנייה שהוקצה לו"** (ראה פרוטוקול מיום 29.5.13, עמ' 5 שורות 2-5). כהן העיד עוד כי: **"כל דייר משתמש בחניה שהוקצה(ת) לו למעט המקרה ששנוי המחלוקת (צ"ל- "במחלוקת") בתביעה זו"**.

85. כשנשאל כהן מדוע לא זומנה אסיפה כללית או לא נעשתה פניה לבית המשפט (בשים לב לכך שלא בוצע בסופו של דבר רישום החניות במרשם המקרקעין) ענה כהן, בין היתר, את הדברים הבאים-

"היות וההחלטה על חלוקת החניות כפי שנתקבלה ונחתמה בתשריט קיימת ופועלת כסדרה אף אחד לא רואה עניין מיוחד ברישום הטאבו מלבד המקרה שנדון כאן..."

86. כהן טען בעדותו כי על אף שגדות לא נכח באותה אסיפה בה הוחלט על חלוקת החניות- **"הוקצתה לו חנייה והתקבלה הסכמתו"**. כהן הבהיר כי **"ההקצתה (צ"ל- "הקצאה"- י.ע.ש) הייתה לכל הדיירים כולל עו"ד גדות אחרת לא ניתן היה לקבל את הסכמת עו"ד גדות"** (עמ' 6 שורה 22). לטענתו, גם תיעוד הסכמת גדות מצוי בידי יעקובי (ראה בעמ' 6 שורות 18-19, וכן בשורה 25).

87. גירסתו של כהן, לפיה חלוקת החניות נעשתה בין כל 12 הדירות, ובכללן גם לדירת התובע, לא נסתרה ואף התחזקה בחקירתו הנגדית. עדותו של כהן בפני הייתה אמינה מאוד, והתרשמתי כי הוא עד אובייקטיבי אשר אין לו כל אינטרס בהליך, דבר המעצים את משקל עדותו.

88. זאת ועוד. עדותו של כהן אף חוזקה בעדותו של מר יעקב מור (להלן: "מור"), בעל דירה בבית המשותף בעצמו. מור העיד כי הוא עצמו השתתף **"בישיבה שבה הוחלט לחלק את החניה"** (ראה פרוטוקול הדיון מיום 8.9.13, שורה 38), וכן הבהיר כי **"בסופו של יום חולקו 12 חניות כמספר הדיירים"** (ראה בעמ' 8



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

שורה 5). גם מור חזר בעדותו על כך שחלוקה זו קיימת בפועל, הלכה למעשה, על אף שלא ניתן לה ביטוי רישומי (עמ' 6 שורות 44-42).

89. מור אישר בעדותו כי החניה ב"שטח המחלוקת" היא אחת מאותן חניות שחולקו (עמ' 8, שורות 11-9). גם עדותו של מור הייתה אמינה מאוד, והותירה רושם כי ניתנה באופן אובייקטיבי וחסר פניות.

90. עד נוסף אשר העיד מטעם התובע, גם הוא בעל דירה ומי שכיהן בעבר כנציגות הבית המשותף, הוא מר צבי רביב (להלן: "רביב"). רביב, אשר החליף את יעקובי בתפקיד יו"ר הנציגות, חזר על כך שלא קיבל מיעקובי חומר כלשהו, שכן האחרון סרב להעביר את החומרים שהיו מצויים בידיו מתוקף תפקידו כנציגות (ראה פרוטוקול הדיון מיום 8.9.13, בעמ' 8 שורות 36-29).

91. באשר לאופן חלוקת החניות, העיד רביב כי זו נעשתה גם באסיפה כללית אולם גם "בכל מיני דיונים בין שכנים שמר יעקובי נכנס להחתיים בעלי דירות". כשנשאל מתי התברר כי התקבלה החתימה האחרונה ענה כי- "כאשר כונסה אסיפת דיירים בביתה של הגב' מזרחי, מסר יעקובי שהחתימות קיימות והועברו לעו"ד ושהוא רכש את החניה של משפ' גרשון. אני לא זוכר מתי אבל יש פרוטוקול של האסיפה" (ראה בעמ' 9 שורות 25-17).

92. עוד העיד רביב כך- "אנחנו לא היינו מודעים לכך שלא נעשה שום רישום. מה שעניין אותנו זה מניעת סכסוך בעתיד. ולכן התקשרנו עם עו"ד גדות שהיה הבעלים לפני זעזוע הודענו לו שהמצב הוא שמר גרשון חונה בחניה שהוקצתה בהסכם בין הדיירים לו..." (עמ' 10 שורות 21-19).

93. עדותו של רביב, אף היא, הייתה אמינה בעיני, והתרשמתי כי הוא עד ניטרלי שאין לו כל עניין אישי בסכסוך בין הצדדים.

94. גם המסמכים אשר הוצגו בפני מחזקים את המסקנה העולה מעדויות אלו, לפיה בהסכמת כל בעלי הדירות התבצעה ואף נהגה חלוקה של הרחבה ל-12 חניות, בפועל. כך למשל, מוצג ת/1, בפרוטוקול אסיפת הדיירים מיום 28.4.04, מדובר, על חלוקת החניות ועל מחויבותם של הדיירים לחנות רק במקומות שהוקצו להם. כך גם, נספח ת/3 שכותרתו "הסכם והתחייבות בין ועד הבית הדישון 18 לבין משפחת מור דירה 11", והדנה בקבלת תשלום מיוחד עבור חניה מידי משפחת מור, מצוין, בין היתר, כי : "נתקבל צ'ק... המהווה תשלום עבור הצמדת החניה ... כפי שנקבעה והוסכמה על ידי כל דיירי הבניין..." (ההדגשה שלי- י.ע.ש).

95. מנגד, טענותיו של הנתבע לא נתמכו בכל עדות חיצונית.

96. הנה כי כן, מעדותם של כהן, מור ורביב וכן מהמסמכים אשר הוצגו בפני כמפורט לעיל, עלתה תמונה עובדתית מהימנה ולפיה בעלי הדירות כולם החליטו על חלוקה של 12 חניות, לכל בעלי הדירות (לרבות אלו שהייתה בידם חניה צמודה), וחלוקה זו אף נהגה ועודנה נוהגת בפועל, הלכה למעשה (למעט המחלוקת בהליך דנן). כעולה מהמסגרת המשפטית עליה עמדתי לעיל, מדובר בחלוקה מוסכמת של זכויות השימוש ברכוש המשותף וככאלו הן מחייבות את כל בעלי הדירות- כל עוד לא חזרו בהם בעלי הדירות מההסכמה (ובכפוף ליכולתם לעשות כן בשים לב להסתמכות ושינוי מצב לרעה).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

97. **כן עלה** (וראו למשל את עדות רביב לעיל) **כי החניה בשטח המחלוקת היא זו אשר הוקצתה לדירת התובע וכי הנתבע עושה בה שימוש, לאחר שהוא עצמו מכר את החניה שברשותו ליעקובי.**

98. אעיר, כי הוכח בפני כי אותה חלוקת חניות המשיכה לנהוג גם לאחר שבחלק מדירות הבית משותף נעשו עסקאות מכר (ראה למשל: עדות כהן לפיה גם הדייר אשר קנה ממשפחת דביר את דירתם משתמש בחניה שהוקצתה לדירה זו- עמ' 5 שורות 25-26). לא הובאו בפני כל ראיות התומכות בטענת הנתבע כי החלוקה המוסכמת בוטלה לכאורה וכי בעלי הדירות חזרו בהם כביכול מהסכמתם.

99. על בסיס הראיות והעדויות שהוצגו בפני כאמור לעיל, הרי שמסקנתי היא כי המסמכים, לרבות התשריט ופרוטוקולי האסיפה הכללית בהם הוחלט על החלוקה, מצויים אצל יעקובי או מי מטעמו, אולם זה נמנע בכוונת מכוון מלהציגם. בשל העובדה כי יעקובי רכש את החניה אשר הוקצתה לנתבעים, הוא בעל אינטרס בהליך לטובת הנתבעים, וככל הנראה הוא סבור כי הימנעותו מהצגת המסמכים תסייע בידי הנתבעים.

100. עדותו של יעקובי, יש להוסיף, לא הותירה עלי רושם מהימן כלל וכלל. טענת יעקובי כי חולקו רק 11 חניות (דהיינו לכל הדירות מלבד לדירת התובע) שכן **"עו"ד גדות היה נוח והסכים איתנו על הכל"** (ראה בעמ' 10 שורה 5), איננה נתמכת באף ראיה ואף נסתרת בעדויות בעלי הדירות השונות (כהן, רביב ומור) אשר עדותם הייתה אמינה עלי. יתרה מכך, הטענה כי גדות הסכים כביכול לחלוקת חניות באופן בו הוא לא מקבל כל חניה נוספת, אף נסתרת מנספח 5 לכתב התביעה – מכתבו של גדות ליו"ר הנציגות דאז, כהן. במכתב זה, מיום 3.8.10, המתייחס אל פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 21.7.10, מציין גדות במפורש את **"שטח החנייה שהוקצה לדירה שלנו (נוסף על השטח המקורה שהוצמד לדירה ורשום בטאבו) שבו החלו לחנות, ללא הסכמתנו, משפחת גרשון..."** (וקובל על כך שנושא מכירת החניה ליעקובי ואזהרת משפחת גרשון לא הובא לידי ביטוי בפרוטוקול (ראה גם עדות רביב, עמ' 10, שורות 19-23)).

101. הנתבעים מבקשים להיתלות בכך שלא קיים כל חומר כתוב, שכן לא הוצגו הפרוטוקולים או התשריט הנוגעים לחלוקת החניות, ולפיכך לטענתם לא הוכחה החלוקה ולא הוכח כי לדירת התובע הוקצתה חניה כנטען. אולם, נראה כי אי הצגת הפרוטוקולים והתשריט נעשו במחשבה תחילה ובסיועו של יעקובי, אשר המסמכים מצויים בידי. לפיכך, אין לזקוף את היעדרם לחובתו של התובע.

102. בעדות הנתבע 2, יניב, הובהר באופן חד משמעי כי הנתבעים מכרו ליעקובי את החניה שהוקצתה להם, תמורת תשלום נכבד, וכי בהיותו של יניב בעל רכב הוא נאלץ לחפש לעצמו מקום חניה אחר, ועל כן הוא מחנה את רכבו בשטח המחלוקת. על אף שהנתבעת הוזהרה מפני מכירת חנייתה פן לא יישאר לה מקום להחנות בו רכב מטעמה (ראה למשל פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 2.4.08 וכן ההערה שנוספה בסעיף 12, נספח 2 לתצהיר התובע, ראה גם נספח 7 לתצהיר התובע, סעיף 6 לתצהיר כהן, סעיף 5 לתצהיר רביב), לא שעו הנתבעים לעצת חברי הנציגות אשר פנו אליהם, ומכרו את "זכות השימוש" אשר ניתנה להם בחניה, ליעקובי. התוצאה היא, כי הנתבעים החלו לחנות ב"שטח המחלוקת", וזאת משום שתחילה היה פנוי (שכן גדות השכיר את הדירה לשוכר שלא היה ברשותו רכב). כשרכש התובע את זכויות הבעלות בדירה, הציגו הנתבעים בפניו "עובדה מוגמרת", ולא אפשרו לו לחנות שם את רכבו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

103. יתרה מכך, הנתבעת, אשר נכחה בישיבות האסיפה הכללית ואף הוזהרה, כאמור לעיל, מפני תוצאות מכירת החניה שהוקצתה לה ליעקובי, נמנעה מלהגיש תצהיר ולהעיד בהליך זה. מטעם הנתבעים הוגש תצהירו של יניב בלבד, אשר אין חולק כי לא נכח בישיבות האסיפה הכללית, בהן הוחלט על חלוקת החניות.

104. באשר למשמעות של הימנעות מהבאת עדים נקבע, בין השאר, על ידי כב' השופטת בן עתו (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פ"ד לה (1) 736 (1980), בעמ' 760):

"כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראייה שהיא לטובתו ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר, ניתן להסיק שאילו הובאה הראייה הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים וככל שהראייה יותר משמעותית כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות יותר מכריעות ויותר קיצוניות נגד מי שנמנע מהצגתה".

בעניין זה ראה גם: ע"א 635/89 אנקונה נ' גוטמן תק-על 705 (3) 90 (1990); ע"א 27/91 קבלו נ' שמעון פ"ד מט (1) 450 (1995); יעקב קדמי על הראיות - הדין בראי הפסיקה (מהדורה משולבת ומעודכנת, תשס"ד), עמ' 1650.

105. המסקנה היא, כי הנתבע מסיג את גבולו של התובע בשטח המחלוקת. לפיכך אני מורה על מתן צו האוסר על הנתבעים להחנות את רכבם בשטח המחלוקת.

106. באשר למתן דמי שימוש, דרש התובע 800 ₪ עבור 22 חודשים בהם חנה הנתבע בחניה המהווה את שטח המחלוקת. התובע רכש את הדירה על פי תצהירו באוקטובר 2010 (עובדה שהנתבעים לא הכחישו), ומאז חנה הנתבע בשטח המחלוקת. התובע ביקש בכתב תביעתו דמי שימוש עבור 22 חודשים.

107. בהתאם לסמכותו לפי סעיף 72 לחוק, כשדן המפקח על רישום מקרקעין בהסגת גבול, מוסמך הוא גם לתת כל "סעד אחר" הנדרש בקשר עם התובענה, לרבות פסיקת דמי שימוש ראויים. זאת, בשים לב לסעיף 74 לחוק - המקנה למפקח את כל הסמכויות שיש לשופט שלום בתביעה אזרחית, וכן בהתבסס על סעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, אשר קובע סמכות כללית לפיה - "כל בית משפט הדן בעניין אזרחי מוסמך לתת פס"ד הצהרתי, צו עשה, צו אל תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו".

108. התובע לא הציג ראיות או אסמכתאות בנוגע לשומת דמי השימוש בחניה, כך שהיא נעשתה ללא הוכחה. יחד עם זאת, לא יכול להיות חולק כי קיים ערך כספי לחניה (כך אף לשיטת הנתבעים אשר בחרו למכור את החניה תמורה כ-20,000 ש"ח). לפיכך, אני קובעת על דרך האומדנה כי שווי השימוש בחניה הנו 300 ₪ לחודש, ובחישוב של 22 חודשים (מספר החודשים כמבוקש בכתב התביעה) דמי השימוש הנם 6,600 ₪.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

109. אשר על כן, אני מורה לנתבעים להשיב לתובע סך של 6,600 ₪ בגין דמי שימוש ראויים בחניה בשטח המחלוקת. התובע לא עתר בתביעתו לתשלום דמי שימוש בגין התקופה שמאז הגשת התביעה ועד למתן פסק הדין, ועל כן אינני מורה על סעד שכזה.

110. באשר לפיצוי בגין עוגמת הנפש הנטענת, הרי שספק רב אם סעד שכזה מצוי בסמכותי. ממילא, הטענה בדבר עגמת נפש וכן פיצוי בסכום המבוקש לא נתמכה בדי ראיות, ולפיכך סעד זה נדחה.

111. לעת סיום אעיר כי אין בפסק דין זה משום קביעה כלשהי באשר לסמכותה של הנציגות לגבות סכום כזה או אחר בגין הקצאת החניות. לא נדרשתי לנושא זה לשם הכרעה בהליך. הכרעתי מבוססת על כך כי שוכנעתי כי אכן נעשתה חלוקה בהסכמת כל בעלי דירות לחלוקת הרחבה ל-12 חניות (בנוסף ל-4 הרשומות במרשם המקרקעין), כאשר החניה שהוקצתה לדירת התובע היא בשטח המחלוקת, וחלוקה זו נהגת בפועל, ולפיכך – עשו הנתבעים שימוש בחניה שהוקצתה לדירת התובע, שלא כדין.

ד. סוף דבר

א. ניתן בזה צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים להחנות את רכבם או כל רכב אחר מטעמם ולתפוס כל סוג של חזקה בשטח המחלוקת.

ב. הנתבעים ישלמו דמי שימוש ראויים בסך 6,600 ₪ לתובע, וזאת בתוך 30 יום.

ג. הנתבעים יישאו בהוצאות משפט של התובע בסך 3,000 ₪.

ד. הסכומים המפורטים לעיל ישולמו בתוך 30 יום ולאחר מכן יישאו ריבית והצמדה כדין.

ניתן היום, כה' אדר א' תשע"ד, 25 פברואר 2014, בהיעדר הצדדים.

המזכירות תשלח לצדדים בדואר רשום + אישור מסירה.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת על רישום מקרקעין